

1512062-27.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/07/2022
... policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512062-27.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1512062-27.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137061/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 25082358 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2137061 - 49º D.P. SAO MATEUS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KELVIN LÚCIO DE MOURA e outro
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

KELVIN LÚCIO DE MOURA e WESLEY SANTOS OLIVEIRA RAMOS foram denunciados por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Kelvin também foi denunciado por incursão no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal, em concurso material, e DANÚBIA ALVES CARVALHO foi denunciada por incursão

no caput do artigo 14 da Lei nº 10.826/04.

Narra a denúncia que no dia 18 de maio de 2022, os denunciados KELVIN e WESLEY, previamente conluiados para a prática de delito patrimonial, por volta das 23h10min, avistaram o momento em que as vítimas Cleiton e Beatriz estacionaram o veículo Fiat/Uno de placas RFW-6G73 na via pública e, aproveitando-se da oportunidade, deles se aproximaram, KEVIN com arma em punho, e anunciaram o assalto. Nesse contexto, com os ofendidos subjugados, os averiguados deles subtraíram documentos pessoais, alianças e aparelhos celulares (Xiaomi e Apple). Após, embarcaram no automóvel Fiat/Uno de placas RFW-6G73 e se evadiram do local. Consta, ainda, que na madrugada do dia 19 de maio de 2022, por volta das 02h10min, o réu KELVIN, agindo desta vez sozinho, abordou a vítima Fábio que conduzia o táxi Toyota/Corolla de placas GER-4A34 e, portando arma de fogo, anunciou o assalto. O ofendido, temendo por sua integridade física, prontamente obedeceu aos comandos do denunciado, oportunidade em que ele subtraiu da vítima uma aliança, três aparelhos celulares (Motorola, Samsung e LG), documentos pessoais e cartões bancários e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, o réu KELVIN se evadiu na posse do veículo Toyota/Corolla de placas GER-4A34 da vítima. Consta, por fim, que na Avenida Adélia Chofi - Mauá, no interior do veículo Fiat/Pálio de placas COG-1659, com a acusada DANÚBIA, foi localizado e apreendido um revólver, calibre 38, marca Taurus, número 55733. Recebida a denúncia, os réus Kelvin e Wesley foram citados (fls.215-6) e apresentaram respostas à acusação. Foi determinado o desmembramento dos autos em relação à acusada Danúbia (fls.225-8).

As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, os réus Kelvin e Wesley foram interrogados.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da menoridade relativa do réu Kelvin e confissão, a declaração de inconstitucionalidade material da fração de aumento em razão do emprego de arma, bem como a fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 17-22), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 26-7), auto de reconhecimento de pessoa (fls.32-3, 34-5 e 36-7), laudo pericial (fls. 182-5, 186-9 e 194-8), além de prova oral colhida. A autoria é certa.

O réu Kelvin, em solo policial (fl. 14), permaneceu em silêncio. Em juízo, manifestou-se (mídia digital).

O réu Wesley, na fase administrativa (fl.15), permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que não participou do roubo, apenas dirigiu o veículo. Viu as vítimas, mas não teve contato com elas (mídia digital).

A vítima Fabio, na fase antejudiciária (fls.06-7) disse que: (sic) "é taxista e exercia suas funções na posse de seu veículo Corolla, placas GER4A34, na madrugada de hoje, por volta das 02h10 ia pegar uma passageiro, na Av. Presidente Castelo Branco, Bairro Zaíra, no município de Mauá, região da Grande São Paulo, momento em que foi abordado pelo indiciado que soube chamar-se KELVIN, o qual veio correndo na direção do declarante, portando uma arma de fogo, mais precisamente um revólver de cor escura, anunciando o assalto, ordenando que o declarante entregasse seus

pertences, incluindo três aparelhos de telefonia celular, um LG, um SAMSUNG e o outro MOTOROLA, todos recuperados por policiais militares, uma aliança, também recuperada, e documentos pessoais, e R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, cartões de créditos/débitos de instituições financeiras diversas, já bloqueados pelo declarante, estes não encontrados e o veículo, também recuperado pelos mesmos policiais que detiveram KELVIN, junto com outras pessoas, desconhecendo o declarante em que circunstâncias se deu essa prisão. O declarante soube pelos mesmos policiais que um casal também fora vítima do mesmo ladrão ao qual fez menção o declarante. (...) O declarante, após a apresentação da ocorrência, foi convidado a descrever a pessoa que o assaltou e, em seguida, na presença da autoridade policial foi até a Sala de Reconhecimento desta Unidade Policial e, dentre outras pessoas, não teve qualquer dúvida em apontar, com cem por cento de certeza, KELVIN como a pessoa que anunciou o assalto, conforme anteriormente mencionado pelo declarante e, pelo que pode perceber, agiu sozinho".

Em juízo, afirmou que parou para buscar um passageiro e o réu apareceu com a arma de fogo apontando em sua direção. Arrancou sua aliança, abriu a porta, tirou seu cinto de segurança, pediu para descer e levou o carro embora. Foi abordado por apenas uma pessoa. Soube do roubo do outro veículo Uno, estava na Delegacia e chegou o casal vítima. O veículo e celular roubados tinham rastreador. O diretor da central dos taxistas ficou passando as informações do celular aos policiais, que conseguiram abordar os réus. Na Delegacia reconheceu o réu que roubou seu veículo. O acusado estava de touca, era branco e baixo, viu o rosto dele. Em juízo, reconheceu o acusado Kelvin (mídia digital).

A vítima Cleiton, na fase administrativa (fls.10-1), disse que (sic) "é namorado de BEATRIZ, estavam juntos, pois iria levá-la de volta para a casa dela e quando parou em frente a residência dela, Rua Augusto Calheiros, nº 1003 - no município de Mauá/SP, sendo isso por volta das 23h10m de ontem, foram surpreendidos por duas pessoas, reconhecidas após a apresentação da ocorrência nesta Delegacia em Sala adequada para esse fim, não tendo quaisquer dúvidas em apontá-los como os autores do roubo, KELVIN e WESLEY, e KELVIN era quem portava o revólver aqui apresentado e anunciou ao assalto, inclusive reconheceu a sua blusa de moletom que WESLEY estava usando no momento desse procedimento. A ação foi rápida, sendo que os pertences do declarante e de sua namorada foram subtraídos, quais sejam as alianças de ambos, aparelho de telefonia celular do casal, sendo essas jóias e o aparelho de telefonia móvel do declarante, da marca XIAOMI, além do carro Fiat Uno Atractive, placas RFW6G73 emplacamento do Estado de Minas Gerais (locado). (...) Reconheceu também o revólver aqui exibido, antes mesmo da apresentação da ocorrência, mostrado pelos policiais que detiveram os assaltantes acima nominados, como sendo a mesma arma que KELVIN portava quando anunciou o assalto. Foi WESLEY quem assumiu a direção do veículo em que o casal estava, sendo que os dois assaltantes empreenderam fuga na posse dos pertences mencionados. Salaria o declarante que os dois assaltantes, chegaram correndo e não viu se tinha algum veículo próximo a eles que estivesse no apoio. Cerca de trinta minutos depois, o veículo fora localizado em estado de abandono (...)"

No mesmo sentido o depoimento da vítima Beatriz (fls.08-9).

Em juízo, a vítima Beatriz disse que estava com seu namorado e tinham acabado de estacionar na porta de sua casa, quando foram abordados pelos réus, um do lado do motorista e o outro do seu lado. Pegaram seus pertences, fizeram seu namorado tirar a blusa de frio e levaram o carro. Utilizaram seu cartão para abastecer o outro veículo deles. Na madrugada os policiais informaram que tinham encontrado seu RG. Na Delegacia, foram apresentados seis homens e reconheceu os réus. Um dos réus era mais alto e moreno, o outro era mais baixo, branco e tinha o cabelo meio laranja. Em juízo, reconheceu os réus Kelvin e Wesley (mídia digital).

Sob o contraditório, a vítima Cleiton, afirmou que levaram seu veículo, aliança e aparelho celular. Disse que duas pessoas participaram do roubo e viu arma de fogo.

Na Delegacia foram apresentadas seis pessoas e reconheceu os réus. Um deles era baixo, com o cabelo pintado, e o outro era alto e moreno, os dois eram magros, com olhos castanhos. Os indivíduos não eram parecidos quanto ao tamanho, cabelo. Em juízo, reconheceu os réus Kelvin e Wesley (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

A jurisprudência dos Tribunais, em lição tradicional, admite que o reconhecimento judiciário refuja ao rigor da regra do referido art. 226, sem perder, com isso, seu valor de "precioso elemento de prova subsidiária" (RT 176/149 -apud e com abono de Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, n. 478, in fine).

O policial militar José Bonifácio, na fase administrativa (fls. 02-3), historiou que: (sic) "componente da Vtr M-30104, na companhia da segunda testemunha, foram informados, via COPOM, sobre ocorrência de Roubo, no Posto Ipiranga, localizada na Avenida Castelo Branco, altura no numeral, 885, Bairro Jd Zaíra, na Cidade de Mauá. Incontinentemente, rumaram até o local e lá entraram em contato com a pessoa de prenome FÁBIO, o qual disse que é taxista e foi roubado por um indivíduo, cinco minutos antes da chegada dos policiais, o qual chegou a pé, portando um revólver escuro, defronte ao posto, e levou o seu veículo Toyota/Yaris de placas GER4A34 e seus aparelhos telefônicos, um da marca Samsung, outro da marca Motorola e o último um LG, e cinquenta reais em dinheiro. Ainda no local, os policiais militares, cerca de dez minutos depois, foram informados que o referido veículo foi localizado na Rua Pôr do Sol, altura do numeral 123, Bairro Parque das Flores, Cidade de São Paulo. Diante disso, foram até o endereço citado, onde estava o veículo da vítima FÁBIO, momento em que este disse que um dos aparelhos telefônicos possuía rastreador, fornecido pela empresa que trabalha como taxista, e que o rastreamento apontava na divisa São Paulo e Mauá, ainda em constante movimento. Prontamente, se deslocaram, a fim de realizar patrulhamento próximo ao local e foram informados em seguida que o aparelho telefônico transitava na Rua Oratório, até chegar na Avenida Adélia Chohfi, onde abordaram um veículo Pálio de placas COG-1659, com cinco indivíduos. Os indivíduos se identificaram como Kelvin Lúcio De Moura, Wesley Santos Oliveira Ramos, Valério Lucas Neto, Danúbia Alves Carvalho e Suellen Cristina De Sena e, em revista pessoal, por meio da policial feminina Cb PM Thaís, foi encontrado com a pessoa de DANÚBIA, um revólver escuro. Em revista veicular, localizaram três aparelhos telefônicos, um da marca Samsung, outro Motorola e o último um LG, conforme descrito pela vítima, além de mais um aparelho telefônico Xiaomi. Ademais, os policiais militares afirmam que localizaram um documento de identidade em nome de Beatriz De Oliveira Navarro, três alianças e cinquenta reais em dinheiro. Indagados, todos negaram qualquer crime e não quiseram se pronunciar sobre os aparelhos telefônicos. (...) Aqui nesta Distrital, o depoente e seu colega de farda enquanto aguardavam o atendimento, entraram em contato com números por meio de mensagens que chegavam pelo aparelho telefônico Xiaomi, em que a pessoa que atendeu disse ter sido vítima de roubo recente e se identificou como BEATRIZ, e disse que foi subtraído seu documento de identidade, aparelho telefônico Xiaomi, alianças sua e de seu namorado CLEITON, e o veículo que havia sido recuperado por policiais militares e estava na sua residência".

No mesmo sentido o depoimento do policial Rodrigo (fls.04-5).

Em juízo, o policial José Bonifácio afirmou que foi irradiado, via copom, veículo produto de roubo. No local, após contato com a vítima, conseguiram localizar o veículo em região próxima. Um dos celulares da vítima tinha rastreamento e foi

passando as informações para as viaturas. Conseguiram abordar um veículo, com cinco indivíduos. Na revista, a acusada Danúbia estava com um revólver embaixo do braço e dentro do veículo foram encontrados vários pertences das vítimas. Os réus negaram a prática do roubo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma aceção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Diante da prisão dos réus, logo após a prática dos roubos, na posse dos bens das vítimas e da arma de fogo utilizada nos roubos, das declarações seguras das vítimas sobre a participação dos réus nos delitos, além dos reconhecimentos na fase antejudiciária e em juízo, a responsabilidade penal dos denunciados é incontroversa.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram devidamente provadas diante da prova oral colhida, notadamente a palavra das vítimas, e do laudo pericial (fls. 182-5).

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas do roubo do Fiat Uno-delito mais grave.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu Kelvin no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Em relação ao réu Wesley, fixo em 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (cert. fl. 67 -proc 6519-33.2021), perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. REsp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

"Apelação. Roubo. (...) Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

Penas irreprocháveis. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião do mau antecedente. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Presença de duas condenações pretéritas definitivas, valoradas, cada qual, como circunstância judicial negativa e agravante não configura dupla valoração. Defensoria Pública que insiste na ocorrência de bis in idem, valendo-se de julgado proferido no remoto ano de 2012. Alegação superada, inclusive, pelos Tribunais Superiores. Penas mantidas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1501829-67.2020.8.26.0348; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Na segunda fase, a menoridade relativa do réu Kelvin não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do e. Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao réu Wesley, aumento a pena em mais 1/3, em razão da reincidência específica (cert fl.67 -proc. 803-25.2021), totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. A reincidência específica justifica referida fração de aumento, maior o desvalor da conduta.

Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão em relação ao réu Kelvin, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante na posse dos bens roubados e da arma de fogo utilizada no crime, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão

espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy

Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisum, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do

veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRG no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Além disso, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão em relação ao réu Wesley, considerando-se a tese apresentada em juízo.

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinhio-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando

aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminosa, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o crime teve a subtração de um veículo, bem de elevado valor, além de ter sido praticado por dois indivíduos e com o emprego de arma de fogo. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena em 1/3, pelo concurso de agentes, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para o réu Kelvin e 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa para o réu Wesley. Na sequência, tendo em vista o emprego de arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa para o réu Kelvin e 13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e 30 dias-multa para o réu Wesley.

Diante do concurso formal, uma vez que foram atingidos os patrimônios de duas pessoas (vítimas Cleiton e Beatriz), as penas são acrescidas de 1/6, perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-multa para o réu Kelvin e 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa para o réu Wesley.

Por fim, verificando-se que o réu Kelvin praticou dois delitos de roubo -veículos Fiat/Uno e Toyota/Corolla- de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos. Com efeito, os delitos são da mesma espécie e foram perpetrados com forma de atuação semelhante, um na sequência do outro. Satisfeitos, pois, os requisitos estampados no artigo 71 do Código Penal. Assim, soma-se 1/6 à pena mais gravosa, do roubo do veículo Fiat/Uno, atingindo-se 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 28 dias-multa para o réu Kelvin.

Assim, estabilizam-se as penas em 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 28 dias-multa para o réu Kelvin e 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa para o réu Wesley

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Não bastasse, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, visto que houve a subtração de veículo, praticado com arma de fogo e concurso de agentes. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119). Além disso, o réu Wesley é reincidente específico.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado WESLEY SANTOS OLIVEIRA RAMOS, qualificado nos autos, às penas de 16 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, sob regime inicial fechado, e 35 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal, em concurso formal, e o réu KELVIN LÚCIO DE MOURA, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, sob regime inicial

fechado, e 28 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal, em concurso formal, e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal, na forma continuada.

Denego o apelo em liberdade aos réus, mantidas as condições da custódia cautelar. Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, o veículo apreendido ficará disponível para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, oficiando-se à d. Autoridade Policial para que adote as providências necessárias à realização de leilão do veículo, nos termos do disposto no art. 328 da Lei nº 9.503/97 e arts. 122 e 123 do Código de Processo Penal. Em caso de impossibilidade, em razão do estado de conservação do bem, defere-se, desde já, a destruição. Em relação à arma de fogo apreendida, encaminhe-se ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1º da Resolução 134 do CNJ.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA